
2 0 2 5

제 62 회 변리사 2차 시험

상 표 법 - 해 설

안녕하세요.

김수영 변리사입니다.

무더운 날씨에 시험보시느라 진심으로 고생하셨습니다.

시험보고 난 이후의 느낌이 어떠셨을지는 모르겠으나,

합격한 사람도, 시험 직후 느끼는 바는 각자 다르기에,

혹여나 시험을 마친 현재 골가분한 마음이 아니더라도

결과가 발표될 때까지 고생하셨던 만큼 편안한 마음으로 행복하게 보내시길 바라겠습니다.

올해 상표법 문제의 난이도는,

i) 문제 1번의 난이도는 '상'에 해당하고, 문제 2~4번은 '중하~하' 정도로 판단되어, 전체로써의 객관적인 난이도로는 중~중상 정도로 생각되나,

ii) 문제 1번의 문제 길이 및 지리적 표시 쟁점인 점을 고려하면, 실제 시험장에서 수험생분들께서 느끼셨을 체감 난이도는 중상~그 이상일 것으로 사료됩니다.

iii) 결국, 객관적인 난이도보다는 '체감 난이도'가 시험장에서의 실제 난이도였을 것이므로, 올해 상표법 문제는 까다로운 편에 속한다고 보아도 무리는 없을 것 같습니다.

올해 시험에 합격하던, 아쉽게 탈락의 고배를 마시던,

지금의 기간은 수험생활로 지친 여러분들의 몸과 마음을 보살펴 주어야 하는 시기입니다.

지나간 시험을 복기하느라 그 기간마저 스스로를 갉아먹지 않으셨으면 좋겠습니다.

여러분들의 합격을 진심으로 기원하겠습니다.

문제 1

I. 설문(1)

1. §36㉔ - 상표등록출원서 기재사항
2. §36㉕ - 단체표장의 사용에 관한 사항을 정한 정관
3. §36㉖ - 지리적표시의 정의에 일치함을 증명할 수 있는 서류

II. 설문(2)

1. 정의규정

(1) '지리적 표시'의 정의(§2㉔(4))

(2) '지리적 표시 단체표장'의 정의(§2㉔(6))

(3) 표장

1) 심사기준

지리적 표시 단체표장은 지리적 표시를 보호하는 것을 목적으로 하므로, 다음 각호의 경우를 제외하고는 지리적 표시만으로 구성된 표장 또는 지리적 표시와 상품명을 결합한 표장만을 지리적 표시의 정의에 합치하는 것으로 본다. (표장의 구성에 있어서 해당 지리적 표시를 수식 또는 한정하거나 별도의 식별력을 가진 문자를 결합한 경우 → 정의 규정 위반으로 봄)

[SYK 코멘트: 심사기준을 풍부하게 현출하면 물론 좋겠으나, 수험적 어려움을 감안하였을 때, 간단히만 현출하거나, 심사기준과 동일한 취지에서 사안 해결하였다면 충분할 것으로 사료됩니다]

2) 사안

→ 식별력 있는 K-STAR 결합 → 정의규정 위반

(4) 지정상품

1) 심사기준

지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 경우 그 지리적 표시를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있으므로 원칙적으로 지리적 표시의 정의에 합치됨을 입증하는 자료를 제출한 1개의 상품을 지정상품으로 하여 등록받을 수 있다.(원재료 상품 및 그 원재료 상품의 주원료가 되는 원료로 만든 복수의 가공품 등과 같이 매우 긴밀한 연관관계가 있고, 각각의 지정상품에 대하여 지리적 표시의 정의에 합치함을 입증하는 서류가 제출되는 경우에는 2개 이상의 지정상품을 등록받을 수 있다)

[SYK 코멘트: 심사기준을 풍부하게 현출하면 물론 좋겠으나, 수험적 어려움을 감안하였을 때, 간단히만 현출하거나,

심사기준과 동일한 취지에서 사안 해결하였다면 충분할 것으로 사료됨]

2) 사안

→ '조미구이 김'이 아닌 '김, 조미 김, 구이 김' → 정의규정 위반

2. 출원인 적격

(1) §3㉔

(2) 사안

개인기업 C → 출원인 적격 위반

3. 제출서류(§36㉔,㉕,㉖)

→ 문제되지 않음

4. 기타 거절이유

(1) §33㉔(3),(4)

→ ×(§33㉔)

(2) §34㉔(12)전단

→ ×

(3) §34㉔(10),(14)

→ × (∵ 타인 X)

[SYK 코멘트: 목차 3 및 4는 답안 여유에 따라 간단히 현출 可]

5. 심사 결과

①정의규정 위반(§2㉔(4),(6)), ②출원인 적격 위반(§3㉔) → 거절이유통지 후 거절결정 예상

6. 등록받기 위한 방안

(1) 정의규정 위반

1) 표장

→ "K-STAR" 삭제(심사기준: 지리적 표시 단체표장 및 지리적 표시 증명표장의 출원에 있어서 지리적 표시 부분을 제외한 표장의 나머지 부분을 삭제보정하는 내용의 상표보정은 법 제40조제2항에 의한 출원의 요지변경에 해당하지 않는 것으로 본다.)

[SYK 코멘트: 심사기준 별도로 현출하면 당연히 좋겠으나, 수험적으로 해당 심사기준을 암기하고 있었을 수험생은 없었을 것으로 사료됩니다]

2) 지정상품

“조미 구이 김”으로 보정

(2) 출원인 적격 위반

1) 수정정관 제출(\$43○)

2) 사안

→ “개인기업 C”를 조합원에서 삭제한 수정정관 제출

II. 설문(3)

1. §119○(2)

(1) 의의, 취지

(2) 품질오인 염려 - 일동포천막걸리 判例(2002후2457) or 광천김 判例

(3) 사안

A, F → 품질오인우려 有 & 상당한 주의 無 → ○

2. §119○(7)가목

(1) 의의, 취지

(2) 사안

B, D → 정관 위반 사용으로 품질, 지리적출처오인 우려 有 & 상당한 주의 無 → ○

[SYK 코멘트: 광천김 判例 사실관계상 “D”가 MAIN. 문제 사실관계상 “B”도 여기에서 포섭해주어야 하는 것으로 사료됨. “A”와 “F”도 여기서 함께 포섭은 可]

3. §119○(7)다목

(1) 의의, 취지

(2) 사안

E → 제3자 사용으로 품질, 지리적 출처 오인우려 有 & 甲이 고의로 적절한 조치 X(甲의 오기 관련 진술 내용으로 포섭) → ○

4. §119○(8)가목

(1) 의의, 취지

(2) 사안

F → ○

5. 청구 이유 예상

§119○(2), (7)가목, (7)다목, (8)가목

6. 특허심판원의 심결

인용심결 예상

문제 2

I. 설문(1)

1. 침해죄(\$230)
2. 양벌규정(\$235)
3. 몰수(\$236)

II. 설문(2)

1. 상표권 이전의 효력발생

(1) 게스트하우스 判例 (2023도11044)

(2) 사안

합의 × → 甲: 상표권자 / 乙: 상표권자 ×

2. 일반 수요자에게 판매 & 사은품 내지 판촉용 제공

(1) 침해요건 검토

유.상.보.정.제.남 中 '상' 문제되는 바 이하 검토

(2) 상표적 사용

1) 광고매체가 되는 물품 - 判例

2) 사안

①200개는 일반 수요자에게 판매한 점을 고려하면, ②'수건'은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상품에 해당 ③일부가 사은품 또는 판촉물로서 제공되었다고 하여 그 부분만을 분리하여 상품성 부정할 것은 아니므로(수건 判例(=스피도 判例)), ④상표적 사용 ○

(3) 사안

→ 침해 ○

3. 판매 목적으로 소지

(1) 간접침해(\$108②(4))

(2) 사안

→ 간접침해 ○

4. 침해죄 성립 여부

(1) 일반 수요자에게 판매 & 사은품 내지 판촉용 제공

乙의 위조 행위 → 乙의 고의 인정 → 침해죄 ○

(2) 판매 목적으로 소지

i) 특허법 判例 → 침해죄 ×

ii) 상표법 判例(2018도9903) → 침해죄 ○

[SYK 코멘트: 두 논리 중 어떤 것을 취하여도 무방할 것으로 사료됨]

III. 설문(3)

1. 통상사용권 등록 시 대항할 수 있는 '제3자'

(1) §100①(1)

(2) 통상사용권 제3자 判例(=장우등 判例) (2024다306691)

2. 사안

(1) 甲 권리의 침해인지

→ ×

(2) 乙 권리의 침해인지

→ 24.2.1.부터 침해 ○

문제 3

I. 설문(1)

1. §34⑩(7) 의의, 취지

2. 상표 유사판단

(1) 유사판단 일반론 判例

(2) Rolex 判例

[SYK 코멘트: 배점상 유사판단과 관련된 일반론(문자상표 유사판단, 외국어 상표의 호칭 등) 및 구체적 출처혼동 고려하여 유사여부 판단한 判例(ex. 다이소 判例, saboo 判例 등)를 풍부하게 현출하는 것이 적절하였을 것으로 사료됩니다]

(3) 사안

① 외관, 호칭은 유사하나,

② 乙의 선등록상표는 저명상표이나, 甲의 이 사건 출원상표는 널리 인식되어 있는 상표라고 볼 수 없는 점을 고려하면,

③ 구체적·개별적 출처혼동 우려 ×

④ 비유사 상표

3. 청구이유

①일반적·추상적·정형적으로는 유사하더라도, ②구체적·개별적 출처혼동 우려가 없어 ③비유사 상표임을 주장

II. 설문(2)

1. 심결취소소송(§162)

2. 관련 判例 (2015도789)

상표등록의 출원이 취하된 경우에는 출원이 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 비록 출원에 대한 거절결정을 유지하는 심결이 있더라도 심결의 취소를 구할 이익이 없고 심결취소의 소는 부적법하게 된다.

3. 사안

소각하판결

III. 설문(3)

1. 乙의 선등록상표와의 관계

‘타인’ 해당하지 않으므로 §34①(7) 문제되지 않음

2. 甲의 이 사건 출원상표와의 관계

취하되었으므로 §34①(7) 문제되지 않음

3. 甲의 재출원 상표와의 관계

(1) 공존동의제도

1) 의의(§34①(7)단서, §35②)

2) 취지

[SYK 코멘트: 배점상, 공존동의 관련 일반론을 가능한 풍부하게 서술해야 할 것으로 사료됩니다]

(2) 관련 심사기준

공존동의를 통해 후출원상표가 등록된 이후 선등록(출원) 상표권자가 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 등록받고자 할 경우에는 후출원상표권자의 동의가 필요하다.

[SYK 코멘트: 해당 심사기준을 암기하고 계셨던 수험생은 없었을 것으로 생각합니다. 위 심사기준을 현출하지 않더라도, 일반론상 당연히 甲의 동의를 받아야 할 것이므로, 결론만 올바른 방향으로 가면 충분할 것으로 사료됩니다]

(3) 사안

甲의 동의 없으면 §34①(7)에 해당하여 등록 不可

문제 4

I. 설문(1)

1. 침해요건

유.상.보.정.제.남 중 '상'이 문제되는 바 이하 검토

2. 상표적 사용

(1) '리모콘'의 외부하단표면

- 1) 순수한 설명적 사용 - SONY 判例
- 2) 상표로서의 사용 판단방법 - 判例 [상.태.주.의.정]
- 3) 사안

상표적 사용 ×

(2) '리모콘'의 내부 부품

- 1) 거래시 수요자가 인식할 수 없는 경우 - 判例
- 2) 사안

상표적 사용 ×

3. 결론

침해 ×

II. 설문(2)

1. 산업재산권분쟁조정위원회 회부(§151조의2②)

2. 조정이 성립할 경우(§151조의2③)

조정 성립 → 심판청구 취하간주

3. 조정이 불성립할 경우(§151조의2③)

조정 불성립 → 심판절차 중지 결정 취소 → 심판 재개

III. 설문(3)

1. 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정

(1) §97④

통상사용권은 상표권자의 동의를 받지 아니하면 통상사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다.

(2) 사안

乙의 질권 설정 적법

2. 통상사용권을 목적으로 하는 질권 등록의 효력

(1) §100①(2)

통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정은 등록해야 제3자에게 대항 可

(2) 사안

① A는 질권 설정 등록하지 않았으므로 제3자 丙에게 대항 不可

② A는 질권 행사 不可